CADERNOS JURÍDICOS

Impactos jurídicos

em temas de infraestrutura, improbidade administrativa e governança da informação

v. 2, n. 3, junho de 2022

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CADERNOS JURÍDICOS

Impactos jurídicos
em temas de infraestrutura, improbidade administrativa e governança da informação

v. 2, n. 3, junho de 2022

Os trabalhos assinados são de exclusiva responsabilidade dos autores,
não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.

Av. República do Chile, 100
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20031-917
Tel.: (21) 2052-7994
gedit@bndes.gov.br" "http://www.bndes.gov.br/"

© 2022
Esta publicação está disponível em formato digital em www.bndes.gov.br/bibliotecadigital
Distribuição gratuita
É permitida a reprodução parcial ou total dos artigos desta publicação, desde que citada a fonte.

Edição: Gerência de Editoração e Memória

Coordenação editorial: Sérgio Carijó

Gerência de Editoração: Fernanda Costa e Silva

Copidesque e revisão: Tikinet

Projeto gráfico e diagramação: Refinaria Design

Conselho editorial: Ana Neiva, Cristina Blaso, Elizabeth Pinheiro, Filipe Guedes, Humberto Mota, João Duprat, Leandro Coutinho, Marcus Noronha, Maria Felippe, Paulo Barcellos, Roberto Trindade e Themistocles Neto

I34 **Impactos jurídicos em temas de infraestrutura, improbidade administrativa e governança da informação. – Rio de Janeiro: BNDES, 2022.**

44 p. ; 21 x 29,7 cm -- (Cadernos jurídicos; v.2, n.3)

Título de rodapé: Cadernos jurídicos do BNDES

1. Improbidade administrativa. 2. Saneamento. 3. Gestão da informação. 4. Direito – Brasil – Periódicos. I. Plastina, Ernesto Cavalcanti. II. Título. III. Série.

CDD – 340

APRESENTAÇÃO

Desde sua criação, o BNDES é o principal instrumento de execução de política de investimentos do Estado brasileiro, tendo o foco de sua atuação variado de década a década, conforme as necessidades da nossa sociedade.

Todo colaborador que aqui aporta para o exercício de sua missão aprende a história do Banco e sabe discorrer sobre as fases de sua atuação durante os seus setenta anos de existência. Aprendemos que, em sua primeira década de existência, houve concentração no setor de infraestrutura, migrando, a partir da década de 1960, para o fomento da indústria brasileira, tornando-se o propulsor das privatizações durante os anos 1990.

A partir do início deste século, o BNDES passou a diversificar ainda mais sua atuação, seja por meio de financiamentos ao agronegócio, aos setores de comércio e serviços, às micro, pequenas e médias empresas ou pelas novas rodadas de desestatização e seu atual empenho de induzir princípios e práticas socialmente responsáveis em parceria com seus clientes, fornecedores e demais parceiros.

Desde que ingressei na instituição, nos anos 2000, ouvi, com toda coerência, que o BNDES é a "Casa do Economista". No entanto, sempre percebi que nós, advogados, poderíamos abrir as nossas portas e dividir com os demais operadores do Direito as experiências que vivenciamos em nossos trabalhos. É com orgulho que escrevo, assim, esta apresentação do terceiro número dos *Cadernos Jurídicos do BNDES*.

Este caderno está orientado aos impactos jurídicos em temas de infraestrutura, de improbidade administrativa e de governança da informação. No primeiro parecer, os autores Ernesto Plastina, Janaina Nogueira, Paulo Terra, Roberta Miranda e Vivian Winkel comentam as principais alterações decorrentes da promulgação da Lei 14.026/2020, considerada o novo marco legal do saneamento no país.

No segundo trabalho, Álvaro Braga Lourenço debate os reflexos das inovações implementadas pela reforma da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, alterada pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021) na Lei de Conflito de Interesses (Lei 12.813, de 16 de maio de 2013), advogando a necessidade de se considerar o artigo 12 deste diploma como uma ponte de interpretação entre os dois microssistemas jurídicos.

Finalmente, no terceiro parecer, Humberto Motta Filho busca sugerir estratégias para estruturar uma agenda de "governança da informação" para governos e empresas públicas, em especial na coleta, no tratamento, no armazenamento e na eliminação de documentos e dados.

A edição deste terceiro número dos *Cadernos Jurídicos*, por tudo isso, é a demonstração inequívoca de que os advogados do Sistema BNDES têm muito a compartilhar com o ecossistema jurídico nacional e deve servir de mola propulsora para dar fôlego a futuros trabalhos de igual qualidade.

Boa leitura a todos!

Marcelo Simon da Silva
Superintendente
Área Jurídica 1

SUMÁRIO

6

IMPRESSÕES SOBRE AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO MARCO LEGAL DE SANEAMENTO

18

REPERCUSSÕES DA REFORMA DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA LEI DE CONFLITO DE INTERESSES

28

A GOVERNANÇA PÚBLICA DA INFORMAÇÃO: TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA

IMPRESSÕES SOBRE AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO MARCO LEGAL DE SANEAMENTO

Ernesto Cavalcanti Plastina
Janaína Reis da Costa Nogueira
Paulo Kubrusly Soares Terra
Roberta Backer Gomes de Miranda
Vivian Regina Costa Winkel[*]

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo discorrer brevemente sobre as principais alterações promovidas na Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, a partir da promulgação da Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, considerada o novo marco legal do saneamento no país. São abordados os temas da universalização do serviço, a proibição da celebração de novos contratos de programa, a estruturação da prestação regionalizada do serviço, bem como o aumento da segurança jurídica do setor. Conclui-se que os objetivos do novo marco legal estão vinculados à efetiva aplicação dos dispositivos legais e da interpretação jurisprudencial acerca deles.

Palavras-chave: Novo marco legal do saneamento. Lei 14.026/2020. Universalização do saneamento. Segurança jurídica.

* Respectivamente, advogados, gerente e chefe do Departamento Jurídico de Infraestrutura do BNDES. O conteúdo desse trabalho é de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.

INTRODUÇÃO

Em 28 de julho de 2010, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a Resolução A/RES/64/292 (UN, 2010), na qual, pela primeira vez, o direito à água potável limpa e ao saneamento foi reconhecido formalmente como direito essencial. Essa resolução apelou ainda aos Estados e às organizações internacionais para que intensifiquem os esforços para alcançar a efetivação desse direito.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 2018), um sistema seguro de saneamento é fundamental para a saúde em vários aspectos, desde a prevenção de doenças até a preservação da saúde mental e social. A ausência de saneamento básico contribui para o crescimento de doenças que são, especificamente nos países pobres e em desenvolvimento, letais em crianças abaixo de cinco anos de idade. Esse conceito, disposto nas diretrizes sobre saneamento e saúde (WHO, 2018), estabelece um conjunto de medidas para estimular sistemas e práticas de saneamento seguros para a melhoria da saúde, além de evidenciar a conexão entre o tema e o bem-estar populacional.

Essa pauta se torna ainda mais urgente quando se verificam os índices no Brasil. Segundo o Painel Saneamento Brasil (TRATA BRASIL, [2019]), no ano de 2019, 16,3% da população não tinha acesso à água e 45,9% careciam de coleta de esgoto.

Nesse cenário de ausência de serviços públicos de saneamento, foi promulgada a Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, a qual promoveu grandes alterações na Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Os principais objetivos do novo regramento, denominado Marco Legal do Saneamento, consistem em viabilizar a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como estimular maior eficiência e efetividade em sua prestação, conferindo a eles mais segurança jurídica, incluindo os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

I. PRINCIPAIS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.026/2020

Pode-se indicar quatro grandes pilares de mudanças nas diretrizes nacionais para o saneamento promovidas pela Lei 14.026/2020: (i) estabelecimento de metas visando a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário; (ii) proibição de celebração de novos contratos de programa; (iii) estruturação da prestação regionalizada dos serviços; e (iv) aumento da segurança jurídica do setor.

A. UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O artigo 11-B da Lei 11.445/2007, com nova redação dada pela Lei 14.026/2020, determina que os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico devem definir metas de universalização que garantam o atendimento a 99% da população com água potável e a 90% com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. Obriga também que haja metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.

Segundo o disposto no § 1º do artigo 11-B, os contratos de prestação de serviços de saneamento em vigor que não contiverem tais metas terão até 31 de março de 2022 para viabilizarem essa inclusão.

Contudo, de acordo com o § 2º do mesmo artigo 11-B, para os contratos firmados por meio de procedimentos licitatórios, a celebração de aditivo para a inclusão das metas será opcional, a critério

do titular do serviço, em comum acordo com a empresa contratada. O município, caso não proceda o aditamento do referido contrato de prestação de serviços, na forma do § 2º, inciso III, do citado dispositivo, deverá buscar alternativas, como a prestação direta da parcela remanescente ou a realização de licitação complementar para o atingimento da totalidade da meta (§ 2º, incisos I e II).

Já para os contratos de prestação de serviços de saneamento básico celebrados sem prévio procedimento licitatório, como é o caso dos contratos de programa formalizados entre as companhias estaduais de saneamento básico (CESB) e os municípios, a realização de aditamento para a inclusão das metas previstas no artigo 11-B é obrigatória até 31 de março de 2022.

Vale também ressaltar que, como condição precedente e indispensável à celebração de aditivo para a inclusão das metas de universalização dos serviços – seja para os contratos de programa (ante a obrigatoriedade, na forma do § 1º do art. 11-B), seja para os contratos de concessão precedidos de licitação (com aditamento opcional, na forma do § 2º, inciso III, do art. 11-B) –, será exigida a comprovação da capacidade econômico-financeira da empresa contratada, por recursos próprios ou por contratação de dívida, nos termos do artigo 10-B da Lei 11.445/2007, conforme redação dada pela Lei 14.026/2020.

A metodologia para comprovação da capacidade econômico-financeira das empresas prestadoras dos serviços de saneamento foi regulamentada por meio do Decreto 10.710, de 31 de maio de 2021. Segundo o artigo 1º, § 1º, devem comprovar tal capacidade com vistas a viabilizar a universalização dos serviços de abastecimento de água potável ou de esgotamento sanitário:

> *Art. 1º. [...]*
>
> *§1º [...]*
>
> *I – os prestadores de serviço que o explorem com base em contrato de programa celebrado nos termos do disposto na Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005; e*
>
> *II – os prestadores de serviço que o explorem com base em contrato, precedido de licitação e celebrado com o titular do serviço, de concessão comum regido pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, ou de concessão patrocinada ou administrativa regido pela Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para fins de aditamento dos contratos para inclusão das metas de universalização, observado o caráter opcional para esses casos, conforme previsto no artigo 11-B, §2º, conforme já mencionado anteriormente* (BRASIL, 2021).

A avaliação da capacidade econômico-financeira das empresas prestadoras dos serviços de saneamento de água e esgoto será feita pela entidade reguladora responsável pela fiscalização de seus contratos em duas etapas sucessivas, conforme previsto no art. 4º do Decreto 10.710/2021:

> *Art. 4º [...]*
>
> *I – na primeira etapa, será analisado o cumprimento de índices referenciais mínimos dos indicadores econômico-financeiros; e*
>
> *II – na segunda etapa, será analisada a adequação dos estudos de viabilidade e do plano de captação* (BRASIL, 2021).

Nos termos do art. 10 do decreto, a empresa prestadora do serviço deverá apresentar requerimento de comprovação de capacidade econômico-financeira junto a cada entidade reguladora de seus contratos até 31 de dezembro de 2021, acompanhado de toda a documentação prevista nos artigos 5º e 6º do dispositivo.

Caberá à entidade reguladora competente decidir sobre a capacidade econômico-financeira do prestador do serviço até 31 de março de 2022, conforme o art. 14 do regulamento.

B. PROIBIÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS DE PROGRAMA

Os contratos de programa são disciplinados pela Lei 11.107, de 6 de abril de 2007, que trata de normas gerais de contratação de consórcios públicos, tendo como base o artigo 241 da Constituição Federal de 1988, o qual dispõe que

> *a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos* (BRASIL, 1988).

Segundo o art. 13 da Lei 11.107/2007,

> *deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação constituir para com outro ente da Federação ou para com consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos* (BRASIL, 2005).

Conforme dispõe o § 5º do artigo 13,

> *mediante previsão do contrato de consórcio público, ou de convênio de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da Federação consorciados ou conveniados* (BRASIL, 2005).

Assim, sob a égide desse regramento, foram celebrados os contratos de programa entre municípios e as CESBs, os quais, atualmente, representam a maioria dos contratos de prestação de serviços de saneamento firmados pelas companhias estaduais.

Todavia, com o advento da Lei 14.026/2020, essa realidade será alterada, pois, segundo a nova redação do artigo 10 da Lei 11.445/2007, a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão, por meio de prévia licitação, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, sendo vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária.

A Lei 14.026/2020 também incluiu o parágrafo oitavo ao artigo 13 da Lei 11.107/2005 para estabelecer a mesma proibição de celebrar contratos de programas destinados à prestação de serviços públicos de saneamento básico.

Vale registrar que o legislador, ao aprovar a Lei 14.026/2020, previu em seu artigo 16 que

> *os contratos de programa vigentes e as situações de fato de prestação dos serviços públicos de saneamento básico por empresa pública ou sociedade de economia mista, assim consideradas aquelas em que tal prestação ocorra sem a assinatura, a qualquer tempo, de contrato de programa, ou cuja vigência esteja expirada, poderão ser reconhecidas como contratos de programa e formalizadas ou renovados mediante acordo entre as partes, até 31 de março de 2022* (BRASIL, 2020b).

Ainda no parágrafo único do artigo 16, estabeleceu que

> *os contratos reconhecidos e os renovados terão prazo máximo de vigência de 30 (trinta) anos e deverão conter, expressamente, sob pena de nulidade, as*

> *cláusulas essenciais previstas no art. 10-A e a comprovação prevista no art. 10-B da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, sendo absolutamente vedada nova prorrogação ou adição de vigência contratual* (BRASIL, 2020b).

Contudo, tanto o artigo 16, *caput*, quanto seu parágrafo único foram vetados pelo presidente da República ao promulgar a Lei 14.026/2020. Desse modo, a situação dos contratos de programas atualmente vigentes está regida pelos termos do artigo 17, *caput*, da Lei 14.026/2020: "os contratos de concessão e os contratos de programa para prestação dos serviços públicos de saneamento básico existentes na data de publicação desta Lei permanecerão em vigor até o advento do seu termo contratual" (BRASIL, 2020b).

As relações de prestação de serviços não formalizadas por meio de contrato ou os contratos de programa existentes que não sejam aditados para inclusão das metas de universalização, tendo como base a comprovação da capacidade econômico-financeira da respectiva CESB, serão considerados precários ou irregulares.

Sendo assim, a partir dessas novas regras, o cenário futuro da prestação de serviços por parte das CESBs tende a ser bastante alterado, pois para que uma companhia estadual possa continuar executando seus serviços em determinado município, após o advento do termo final de seu contrato de programa, terá que obedecer ao art. 10 da Lei 11.445/2007 e celebrar um contrato de concessão precedido de procedimento licitatório.

C. ESTRUTURAÇÃO DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

O artigo 3º, inciso VI, da Lei 11.445/2007, com a alteração promovida pela Lei 14.026/2020, assim define prestação regionalizada:

> *Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: [...]*
>
> VI – *prestação regionalizada: modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um Município, podendo ser estruturada em:*
>
> *a) região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião: unidade instituída pelos Estados mediante lei complementar, de acordo com o §3º do art. 25 da Constituição Federal, composta de agrupamento de Municípios limítrofes e instituída nos termos da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole);*
>
> *b) unidade regional de saneamento básico: unidade instituída pelos Estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos Municípios menos favorecidos;*
>
> *c) bloco de referência: agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, estabelecido pela União nos termos do §3º do art. 52 desta Lei e formalmente criado por meio de gestão associada voluntária dos titulares* (BRASIL, 2020b).

Por sua vez, o Decreto 10.588, de 24 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União previsto no art. 13 da Lei 14.026/2020 e sobre a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União, ou geridos ou operados por órgãos ou en-

tidades da União, de que trata o art. 50 da Lei 11.445/2007, definiu a prestação regionalizada nos seguintes termos:

> *Art. 2º A prestação regionalizada de serviços de saneamento visa à geração de ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços, com uniformização do planejamento, da regulação e da fiscalização.*
>
> *§ 1º Para fins de alocação de recursos públicos federais e de financiamentos com recursos da União, ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União, será considerada cumprida a exigência de prestação regionalizada:*
>
> I. *na hipótese de região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, com a aprovação da lei complementar correspondente;*
>
> II. *na hipótese de unidade regional de saneamento básico, com a declaração formal, firmada pelo Prefeito, de adesão aos termos de governança estabelecidos na lei ordinária; ou*
>
> III. *na hipótese de bloco de referência, com a assinatura de convênio de cooperação ou com a aprovação de consórcio público pelo ente federativo* (BRASIL, 2020a).

A partir do cotejo dos dispositivos legal e regulamentar supra, é possível constatar que o artigo 2º do Decreto 10.588/2020 limitou a definição das formas de prestação regionalizada dos serviços de saneamento básico àquelas previstas em seus incisos, pois dispõe que será considerada cumprida a exigência de prestação regionalizada nas hipóteses de constituição de: (i) região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião; (ii) unidade regional de saneamento básico; ou (iii) bloco de referência.

Já a redação do artigo 3º, inciso VI, da Lei 11.445/2007 define prestação regionalizada como modalidade de prestação integrada de serviços públicos de saneamento em área cujo território abranja mais de um município.

O inciso VI traz em suas alíneas o que poderia ser entendido como uma relação não exaustiva das formas de prestação regionalizada. Por outro lado, há quem entenda que a enumeração do referido inciso é exaustiva, portanto, os consórcios públicos e convênios de cooperação não estariam abrangidos entre as formas de prestação regionalizada para todos os fins dessa lei.

A propósito, nos termos do artigo 2º, § 11, do Decreto 10.588/2020, a prestação regionalizada sob a forma de consórcios públicos ou convênios de cooperação poderá ser utilizada para os serviços de limpeza pública, de manejo de resíduos sólidos urbanos ou de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, desde que cumpram os objetivos listados no *caput* do artigo 2º, *in verbis*:

> *Art. 2º [...]*
>
> *§ 11. Para serviços de limpeza pública, de manejo de resíduos sólidos urbanos ou de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, a exigência de prestação regionalizada poderá ser atendida por meio de consórcios públicos, na forma prevista na Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, ou por meio de gestão associada decorrente de acordo de cooperação, desde que observados os objetivos previstos no* caput (BRASIL, 2020a).

Assim, para os casos específicos de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais, o decreto previu expressamente outras possibilidades de prestação regionalizada que não

as listadas em seu artigo 2º, § 1º, permitido a interpretação de que excluiu, *a contrario sensu*, essa aplicação aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Segundo dispõe o artigo 2º, *caput*, do Decreto 10.588/2020, a estruturação da prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico visa gerar ganhos de escala e garantir a universalização e a viabilidade técnica e econômico-financeira dos municípios, incluindo aqueles menos capacitados nesses aspectos. Possibilita-se, assim, que também esses municípios sejam atendidos pelas empresas prestadoras de serviços, que não poderão se encarregar apenas daqueles potencialmente lucrativos; pelo contrário, terão que oferecer os serviços para todos os municípios que compõem a estrutura regionalizada, inclusive os deficitários.

Como forma de estimular a estruturação da prestação regionalizada pelos titulares dos serviços públicos de saneamento básico, o legislador estabeleceu, no artigo 50 da Lei 11.445/2007, com redação dada pela Lei 14.026/2020, que a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União (ou geridos ou operados por órgãos ou entidades da União) está condicionada, entre outras obrigações, à comprovação das seguintes exigências:

> VII – *à estruturação de prestação regionalizada*;
>
> VIII – *à adesão pelos titulares dos serviços públicos de saneamento básico à estrutura de governança correspondente em até* 180 *(cento e oitenta) dias contados de sua instituição, nos casos de unidade regional de saneamento básico, blocos de referência e gestão associada*; *e*
>
> IX – *à constituição da entidade de governança federativa no prazo estabelecido no inciso* VIII *do* caput *deste artigo* (BRASIL, 2020b).

Nada obstante, os artigos 7º e 8º do Decreto 10.588/2020 – que, lembremos, dispõe, dentre outros, sobre a alocação de recursos públicos federais e sobre os financiamentos com recursos da União ou geridos ou operados por órgãos ou entidades da União de que trata o art. 50 da Lei 11.445/2007 – estabelecem:

> *Art. 7º O disposto nos incisos* VII, VIII *e* IX *do* caput *do art.* 50 *da Lei nº* 11.445, *de* 2007, *não se aplica:*
>
> *I – aos recursos alocados por emendas parlamentares por meio da transferência especial prevista no inciso I do* caput *do art.* 166-A *da Constituição, hipótese em que os recursos serão repassados diretamente ao ente federativo beneficiado independentemente de celebração de convênio ou instrumento congênere, na forma prevista no § 2º do art.* 166-A *da Constituição, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias*; *e*
>
> *II – à alocação de recursos públicos federais e financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União em Municípios onde a prestação do serviço público de saneamento básico não esteja regionalizada até o prazo a que se refere o § 1º do art.* 11-B *da Lei nº* 11.445, *de* 2007.
>
> *Art. 8º O disposto nos incisos* VII, VIII *e* IX *do caput do art.* 50 *da Lei nº* 11.445, *de* 2007, *aplica-se aos contratos de concessão e de parcerias público-privadas precedidos de licitação, nos termos do disposto no art.* 175 *da Constituição, firmados posteriormente à data de publicação deste Decreto, exceto às concessões e parcerias público-privadas que:*
>
> *I – tenham sido licitadas ou submetidas à consulta pública anteriormente à data de publicação deste Decreto*; *ou*

> *II – sejam objeto de estudos já contratados pelas instituições financeiras federais anteriormente à data de publicação deste Decreto* (BRASIL, 2020a).[1]

Observa-se que os artigos do Decreto 10.588/2020, acima transcritos, definem balizas temporais para a exigência das condições impostas pelo artigo 50, incisos VII, VIII e IX, da Lei 11.445/2007.[2]

Segundo previsto pelo artigo 7º do decreto, seria desnecessário observar as condições impostas pelos incisos VII a IX da Lei 11.445/2007 para a destinação de recursos federais e financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União: (i) em caso de projeto de saneamento originário de emenda parlamentar prevista no inciso I do *caput* do art. 166-A da Constituição; ou (ii) quando a prestação do serviço público de saneamento básico não estiver regionalizada até o prazo a que se refere o § 1º do art. 11-B da Lei 11.445/2007 (31 de março de 2022).[3]

Por sua vez, o artigo 8º do decreto estabelece que as condições impostas pelos incisos VII, VIII e IX do artigo 50 da Lei 11.445/2007 se aplicam aos contratos de concessão e de parcerias público-privadas (PPP) precedidos de licitação, nos termos do disposto no art. 175 da Constituição Federal, firmados posteriormente à data de sua publicação, com exceção daqueles celebrados posteriormente a 24 de dezembro de 2020, relativos às concessões e PPPs que atendam uma das duas condições previstas em seus incisos.

Os artigos 7º, inciso II, e 8º tratam de situações distintas. Pode-se inferir do artigo 7º, inciso II, que 31 de março de 2022 é o termo final para a dispensa das condicionantes previstas nos incisos VII, VIII e IX do artigo 50 da Lei 11.445/2007 para a alocação de recursos públicos federais e financiamentos com recursos da União (ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União) a todos os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico, independentemente de sua natureza.

Depreende-se ainda do artigo 8º que os contratos de concessão e de PPPs precedidos de licitação, firmados após 24 de dezembro de 2020 e que cumpram uma das condições previstas nos incisos I e II igualmente não se sujeitariam, durante toda sua vigência, às exigências impostas pelos incisos VII, VIII e IX do *caput* do artigo 50 da Lei 11.445/2007.

Ainda no tocante aos contratos mencionados no parágrafo acima, é possível interpretar o *caput* do artigo 8º do Decreto 10.588/2020 no sentido de que as exigências constantes nos incisos VII, VIII e IX do artigo 50 da Lei 11.445/2007 não se aplicariam a tais contratos por todo o seu prazo.

D. AUMENTO DA SEGURANÇA JURÍDICA DO SETOR

Antes da promulgação da Lei 14.026/2020, a fragmentação regulatória diante da competência municipal do serviço de saneamento consistia em fator de insegurança para investidores privados, assim como para a estruturação e implantação de projetos e, em última esfera, para a gestão dos contratos.

---

1 A redação do inciso I do art. 8º foi alterada pelo Decreto 10.710/2021 para deixar explícito que as condições da exceção prevista nesse artigo não são cumulativas.

2 Importante destacar que somente o disposto no inciso II do artigo 7º do Decreto 10.588/2020 se aplica aos contratos de financiamento; o inciso I destina-se aos recursos alocados por meio de emendas parlamentares.

3 "§ 1º Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o *caput* deste artigo terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão" (BRASIL, 2007).

A esse respeito, cabe a transcrição de trecho constante da mensagem de encaminhamento do Projeto de Lei 4.162/2019 ao presidente da República:[4]

> 11. A *grande variabilidade de regras regulatórias se consolidou como um obstáculo ao desenvolvimento do setor e à universalização dos serviços.* A *Constituição Federal atribui a titularidade dos serviços de saneamento básico aos municípios, atribuição acolhida pela Lei n. 11.445/2007, que faculta aos titulares regular diretamente ou delegar a regulação desse setor. Esse arranjo explicitou as diferentes capacidades regulatórias dos diferentes titulares, resultando numa miríade de situações.*
>
> 12. *Doze anos após a edição da Lei n. 11.445, de 2007, o país continua convivendo com um arranjo institucional de mais de 49 agências reguladoras responsáveis pela regulação de 2.906 municípios dos 5.570 existentes, ou seja, 48% dos municípios não possuem nenhum tipo de regulação e num ambiente em que cada município pode ter a sua agência reguladora.*
>
> 13. *Um primeiro problema decorrente deste arranjo, se deve à baixa capacidade regulatória dos titulares do serviço, o que afeta negativamente a eficiência e desenvolvimento do setor de saneamento básico, e influencia na qualidade e preço dos serviços de forma inadequada. Uma segunda consequência da falta de padronização regulatória é a existência de custos de transação relevantes aos prestadores, públicos e privados, que trabalham para diferentes titulares. Estes são obrigados a se adaptar a regras regulatórias potencialmente muito diferentes na prestação de um mesmo serviço.*
>
> 14. *O Projeto de Lei proposto atribui à Agência Natural de Águas* (ANA) *a competência de elaborar normas nacionais de referência regulatória para o setor de saneamento básico, que servirão como balizadores das melhores práticas para os normativos dos diferentes reguladores de saneamento básico do País. Espera-se assim uma elevação na qualidade das normas regulatórias para o setor de saneamento básico e uma maior uniformização regulatória em todo território nacional, enfrentando os problemas apontados acima* (BRASIL, 2019).

Ampliando de forma significativa a competência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o novo marco legal lhe outorga atribuição para regular o saneamento básico integralmente por meio da edição de normas de referência (como padrões de qualidade e eficiência na prestação), da manutenção e da operação, da regulação tarifária, das metas de universalização dos serviços de saneamento básico, entre outras.

Nesse sentido, o artigo 4-A da Lei 9.984, de 17 de julho de 2000, incluído pela Lei 14.026/2020, dispõe:

> Art. 4º-A. A ANA *instituirá normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observadas as diretrizes para a função de regulação estabelecidas na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.*
>
> § 1º *Caberá à* ANA *estabelecer normas de referência sobre:*
>
> I. *padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e na operação dos sistemas de saneamento básico;*

4 Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1787462&filename=Tramitacao-PL+4162/2019. Acesso em: 20 set. 2021.

II. *regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico, com vistas a promover a prestação adequada, o uso racional de recursos naturais, o equilíbrio econômico-financeiro e a universalização do acesso ao saneamento básico*;

III. *padronização dos instrumentos negociais de prestação de serviços públicos de saneamento básico firmados entre o titular do serviço público e o delegatário, os quais contemplarão metas de qualidade, eficiência e ampliação da cobertura dos serviços, bem como especificação da matriz de riscos e dos mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das atividades*;

IV. *metas de universalização dos serviços públicos de saneamento básico para concessões que considerem, entre outras condições, o nível de cobertura de serviço existente, a viabilidade econômico-financeira da expansão da prestação do serviço e o número de Municípios atendidos*;

V. *critérios para a contabilidade regulatória*;

VI. *redução progressiva e controle da perda de água*;

VII. *metodologia de cálculo de indenizações devidas em razão dos investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados*;

VIII. *governança das entidades reguladoras, conforme princípios estabelecidos no art. 21 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007*;

IX. *reúso dos efluentes sanitários tratados, em conformidade com as normas ambientais e de saúde pública*;

X. *parâmetros para determinação de caducidade na prestação dos serviços públicos de saneamento básico*;

XI. *normas e metas de substituição do sistema unitário pelo sistema separador absoluto de tratamento de efluentes*;

XII. *sistema de avaliação do cumprimento de metas de ampliação e universalização da cobertura dos serviços públicos de saneamento básico*;

XIII. *conteúdo mínimo para a prestação universalizada e para a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico* (BRASIL, 2020b).

O propósito da nova competência da ANA é, portanto, incentivar a uniformização das normas regulatórias e, dessa maneira, aumentar a segurança jurídica do setor, impulsionando os investimentos.

Por fim, cumpre registrar que, visando estimular a observância das normas de referência expedidas pela ANA, assim como fez em relação à estruturação da prestação regionalizada, o legislador condicionou a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União (ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União) à observância das referidas normas, conforme dispõe o inciso III do artigo 50 da Lei 11.445/2007, incluído pela Lei 14.026/2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A definição do novo marco regulatório do saneamento básico impõe enormes desafios. O estabelecimento da prestação regionalizada dos serviços, a demonstração da capacidade econômico-financeira dos prestadores para atingir a universalização e a impossibilidade de prorrogação ou celebração de novos contratos de programa, dentre outras diretrizes, exigirão organização, planejamento e transparência dos agentes do setor.

É certo que tais desafios passam pela efetiva aplicação da legislação, assim como pela interpretação a ser conferida pelo Poder Judiciário e pelos órgãos de controle. Nessa toada, espera-se que o Supremo Tribunal Federal não tarde a julgar o mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.492, 6.536, 6.583 e 6.882, ajuizadas contra a Lei 14.026/2020.

Tanto quanto de projetos, investimento e financiamento, o setor necessita de segurança jurídica para se expandir.

Espera-se, portanto, que o novo marco legal seja também o marco da participação ativa de todos os atores do setor – entes públicos, empresas privadas e financiadores –, para que, enfim, o serviço essencial e fundamental do saneamento se torne um direito básico consolidado de cada brasileiro.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 nov. 2021.

BRASIL. Decreto n. 10.588, de 24 de dezembro de 2020. Dispõe sobre o apoio técnico e financeiro de que trata o art. 13 da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, sobre a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou geridos ou operados por órgãos ou entidades da União de que trata o art. 50 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. *Diário Oficial da União*: seção 1 extra B, Brasília, DF, ed. 246-B, p. 32, 24 dez. 2020a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10588.htm. Acesso em: 1 set. 2021.

BRASIL. Decreto n. 10.710, de 31 de maio de 2021. Regulamenta o art. 10-B da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para estabelecer a metodologia para comprovação da capacidade econômico-financeira dos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água potável ou de esgotamento sanitário [...]. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, ed. 102, p. 3, 31 maio 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10710.htm. Acesso em: 1 set. 2021.

BRASIL. Lei n. 9.984, de 17 de julho de 2000. Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) [...]. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, p. 1, 18 jul. 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9984.htm. Acesso em: 11 nov. 2021.

BRASIL. Lei n. 11.107, de 6 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, p. 1, 7 abr. 2005.

BRASIL. Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, p. 3, 8 jan. 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm. Acesso em: 1 set. 2021.

BRASIL. Lei n. 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico [...]. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, p. 1, 16 jul. 2020b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm. Acesso em: 1 set. 2021.

BRASIL. *Projeto de Lei n. 4.162/2019*. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2019. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1787462&filename=Tramitacao-PL+4162/2019. Acesso em: 20 set. 2021.

TRATA BRASIL. Indicadores por ano: 2019. *Painel saneamento Brasil*, São Paulo, [2019]. Disponível em: https://www.painelsaneamento.org.br/explore/ano?SE%5Ba%5D=2019. Acesso em: 1 set. 2021.

UN – UNITED NATIONS. A/RES/64/292: Resolution adopted by the General Assembly on 28 July 2010. New York: UN, 2010. Disponível em: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292. Acesso em: 1 set. 2021.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Guidelines on sanitation and health*. Geneva: WHO, 2018. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274939/9789241514705-eng.pdf. Acesso em: 1 set. 2021.

REPERCUSSÕES DA REFORMA DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA LEI DE CONFLITO DE INTERESSES[1]

*Álvaro Braga Lourenço**

RESUMO

Este artigo analisa as repercussões da nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, alterada pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021) na Lei de Conflito de Interesses (Lei 12.813, de 16 de maio de 2013), tendo em vista, sobretudo, o disposto no art. 12 desta última norma, que atua como ponte entre ambos os microssistemas. São analisados os atos de conflito de interesses como atos de improbidade administrativa e abordadas questões específicas surgidas a partir da reforma da Lei de Improbidade Administrativa e seus reflexos na Lei de Conflito de Interesses.

Palavras-chave: Improbidade. Conflito de interesses. Reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Lei de Conflito de Interesses. Lei 8.429/92. Lei 12.813/13.

---

1 Este artigo reflete a opinião do autor, não representando, necessariamente, opinião, estratégia e posicionamento do Sistema BNDES sobre a matéria.

* Secretário-Executivo da Comissão de Ética do Sistema BNDES.

INTRODUÇÃO

Este artigo analisa as repercussões da nova Lei de Improbidade Administrativa, doravante designada como "LIA" (Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, alterada pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021) na Lei de Conflito de Interesses, referida neste texto como "LCI" (Lei 12.813, de 16 de maio de 2013), tendo em vista, sobretudo, o disposto no art. 12 desta última norma, que funciona como ponte entre ambos os microssistemas.

Após breves comentários a respeito da caracterização dos atos de conflito de interesses como atos de improbidade administrativa (item I), passam a ser abordadas questões específicas surgidas a partir da reforma da LIA e seus reflexos na LCI (item II e subitens).

As questões analisadas entram em terreno de intenso debate, havendo argumentos no sentido da defesa do interesse *pro societate* ao enfatizar a característica da Lei de Improbidade Administrativa como mecanismo indispensável para o combate à corrupção (em sentido amplo) e chegando, por isso mesmo, a propugnar pela inconstitucionalidade de certas inovações.

Do outro ângulo da disputa, observa-se um peso maior na necessidade de salvaguardar as garantias fundamentais dos que respondem a processos administrativos sancionatórios, apontando para a impropriedade da redação original da Lei de Improbidade Administrativa e para os excessos cometidos em sua aplicação.

Outra dificuldade diz respeito à compatibilização entre o novo sistema geral, instituído pela Lei 14.230/2021, e as tipificações de atos de improbidade previstas em leis especiais, como as da Lei de Conflito de Interesses, o que criou dificuldades para o aplicador do direito.

Ao concentrar esforços no sistema geral, o legislador pareceu, por vezes, assumir uma aplicação natural das tipificações de atos de improbidade em leis especiais, o que muitas vezes não ocorre, como se nota com a Lei Eleitoral (Lei 9.504/97) que remete a dispositivo atualmente revogado, confirmando-se a máxima italiana segundo a qual "*fatta la legge, trovato l'inganno*".

Este artigo pretende, assim, entrar no debate sobre as inovações implementadas pela reforma da LIA e sua repercussão na LCI, em uma tentativa de colaborar para que se encontre a ponderação mais adequada para a aplicação do art. 12 da LCI, que permaneceu com a redação primitiva.

I. ATOS DE CONFLITO DE INTERESSES COMO ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A LCI enfatiza o diálogo do agente público com o órgão ou a entidade da administração pública a que esteja submetido, oferecendo, no campo preventivo, a possibilidade de ser efetuada consulta "no caso de dúvida sobre como prevenir ou impedir situações que configurem conflito de interesses" (BRASIL, 2013, art. 4º, § 1º).

O sistema da LCI se baseia primordialmente em dois artigos centrais que preveem as condutas de agentes públicos que configuram atos de conflitos de interesses durante (art. 5º) ou após (art. 6º) o exercício de cargo ou emprego federal.

Cabe destacar que, em linha com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, o legislador definiu conflito de interesses como a "situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública" (BRASIL, 2013, art. 3º, inciso I).

Essa definição confere os contornos do conflito entre interesses públicos, de um lado, e privados, de outro, além de nortear a aplicação da lei que busca concretizar, em atos praticados por agente público, o combate à corrupção, em sentido amplo.

Além do objetivo de prevenção, que se materializa nas consultas, a lei também previu que todas as situações que configurassem conflito de interesses fossem caracterizadas, no âmbito repressivo, como atos de improbidade, ao prever, em seu art. 12, que "o agente público que praticar os atos previstos nos arts. 5º e 6º desta Lei incorre em improbidade administrativa" (BRASIL, 2013).

Destaque-se que a Lei de Improbidade Administrativa evidencia essa natureza repressiva da interpenetração de um sistema no outro ao preceituar que "a ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei [...]" (BRASIL, 2021, art. 17-D).

Não é por outra razão que a LIA, em seu art. 1º, § 4º, determinou que fossem aplicados "ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (BRASIL, 2021). A pretexto de se combater a corrupção, não se pode, portanto, suprimir garantias civilizatórias do devido processo administrativo sancionatório.

Ainda com relação à dimensão repressiva, a LCI se comunica com o sistema disciplinar ao criar a possibilidade de demissão do agente público que praticar atos de conflito de interesse, conforme previsão no parágrafo único do seu art. 12, temática que será abordada adiante, em tópico específico.

II. REFORMA DA LIA E REPERCUSSÕES NA LCI

A Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, trouxe substanciais alterações à LIA, estabelecendo novo sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa e, tal como apontado por Marçal Justen Filho (2022, p. 13), as principais inovações são as seguintes:

- *a exigência do dolo, devidamente comprovado, para punição por improbidade*;
- *o sancionamento por improbidade a entidades privadas que tenham recebido o benefício, incentivo ou vantagem de origem estatal*;
- *a eliminação da sanção de perda do cargo ou mandato nas infrações do art. 11*;
- *a restrição ao sancionamento por improbidade do terceiro à comprovação de ter induzido ou concorrido para a prática de improbidade*;
- *a instituição de uma ação judicial típica envolvendo a punição por improbidade com afastamento da aplicação do regime da ação civil pública*;
- *atribuição ao Ministério Público da legitimidade ativa privativa para ação de improbidade*;
- *a ampliação do rigor no tocante aos requisitos de ajuizamento da ação de improbidade com a expressa exigência de qualificação dos fatos em face dos artigos 9º, 10 e 11 da lei 8.429*;
- *a vedação ao julgamento antecipado da lide nas hipóteses de condenação do réu*;
- *a fixação de prazo prescricional de 8 anos, computado a partir da data de consumação do ilícito*;

- *a previsão da prescrição intercorrente computado a partir do ajuizamento da ação de improbidade, com prazo de oito anos.*

Conforme ressaltado, o art. 12 da LCI representa a face repressiva desse estatuto ao enquadrar, no *caput*, os atos de conflito de interesse como atos de improbidade administrativa, fazendo as seguintes remissões a artigos da LIA:

> *Art. 12. O agente público que praticar os atos previstos nos arts. 5º e 6º desta Lei incorre em improbidade administrativa,* ***na forma do art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, quando não caracterizada qualquer das condutas descritas nos arts. 9º e 10 daquela Lei****.*
>
> *Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput e da aplicação das demais sanções cabíveis, fica o agente público que se encontrar em situação de conflito de interesses sujeito à aplicação da penalidade disciplinar de demissão, prevista no inciso III do art. 127 e no art. 132 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou medida equivalente* (BRASIL, 2013, *grifos nossos*).

A partir da reforma da LIA, analisaremos as seguintes repercussões na LCI: (i) exigência de comprovação do dolo específico para a transposição de um sistema ao outro (item A); (ii) esvaziamento na aplicação do art. 11 da LIA, em função de nova opção legislativa (item B); (iii) não aplicação do critério formal da LCI de "meras condutas", exigindo-se a comprovação do resultado, quando houver a tentativa de caracterizar o ato de conflito como ato de improbidade administrativa (item C); e (iv) (im)possibilidade de aplicação da pena de demissão com base na LCI, dentro do novo cenário implementado pela reforma da LIA (item D).

A. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO

A Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, passou a exigir em diversos pontos da LIA a comprovação do dolo específico, imprimindo nova feição à sistemática de responsabilização, uma vez que eram admitidos atos culposos no regime anterior.

Nesse sentido, deve ser ressaltada a inovação contida logo em seu primeiro artigo, em que se consideram, no parágrafo 1º, "atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, *ressalvados tipos previstos em leis especiais*" (BRASIL, 2021, grifos nossos).

Como consequência, a tipificação da LCI deve se ajustar à disciplina da nova LIA para que os atos de conflito de interesse possam ser enquadrados, a partir da aplicação do art. 12 da LCI, como atos de improbidade.

Vale notar que os novos parágrafos do art. 1º da LIA explicitam a ideia de que são considerados "atos de improbidade administrativa as condutas *dolosas* tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei" (BRASIL, 2021, art. 1º, § 1º, grifo nosso), tendo o legislador se preocupado, inclusive, em definir o dolo como "a vontade livre e consciente de alcançar o *resultado* ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei" (BRASIL, 2021, art. 1º, § 2º, grifo nosso) – esse último ponto será abordado no item B deste estudo.

A exigência de comprovação do dolo em diversas partes da LIA (BRASIL, 2021), em especial nos seus três artigos centrais que descrevem as condutas relativas aos atos que (i) importem enriquecimento ilícito; (ii) causem prejuízo ao erário; ou (iii) atentem contra os princípios da administração pública (arts. 9º, 10 e 11 da lei, respectivamente), inviabiliza o enquadramento de quaisquer situações que digam respeito a atos culposos.

Nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA deverão ser comprovados os dolos específicos, respectivamente e de forma resumida, no enriquecimento ilícito, no prejuízo ao erário e, no caso do art. 11, a Lei 14.230/2021 previu expressamente que "somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo [art. 11], quando for *comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade*" (BRASIL, 2021, art. 11, § 1º, grifos nossos).

É interessante notar a previsão do parágrafo 1º do artigo 11 da LIA: com relação aos atos de improbidade administrativa tipificados em leis especiais, como é o caso da LCI, deverá restar evidenciada a finalidade de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou para terceiro.

Tais alterações impactam diretamente a caracterização dos atos de conflito de interesse como atos de improbidade, pois essa operação deverá se moldar necessariamente à nova sistemática da LIA, inclusive em relação à comprovação do dolo específico, além de outras consequências como será exposto nos tópicos a seguir.

B. ESVAZIAMENTO NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 11 DA LIA

Sempre houve muito debate acerca da aplicação do art. 11 da LIA, pois o regime legal original previa uma abrangência tanto horizontal, no sentido da textura aberta inerente aos princípios, quanto vertical, uma vez que o rol de condutas era exemplificativo, como indicava a palavra "notadamente" ao final do *caput*, assim como ainda o fazem as redações dos arts. 9º e 10.

Nessa perspectiva histórica, a LCI caracterizava as condutas de seus arts. 5º e 6º como atos de improbidade "na forma do art. 11 [da LIA], [...] quando não caracterizada qualquer das condutas descritas nos arts. 9º e 10 [da LIA]" (BRASIL, 2013, art. 12).

Percebe-se claramente a subsidiariedade no enquadramento do ato de conflito ao art. 11, uma vez que o aplicador deveria verificar, em primeiro lugar, se seria possível o enquadramento da situação de conflito nos arts. 9º e 10 da LIA.

Na reforma levada a efeito pela Lei 14.230/2021, entretanto, houve sensível reorientação do sistema geral, passando a ser previsto na LIA rol taxativo para as condutas listadas no art. 11, conforme nova redação do *caput* deste artigo em que se utiliza a frase "caracterizada por uma das seguintes condutas" (BRASIL, 2021, art. 11) em substituição à palavra "notadamente", que constava na redação original (BRASIL, 1992, art. 11).

Em razão dessa mudança estrutural, entendemos que os atos de conflito de interesse não mais poderão ser enquadrados no art. 11, observado o caso específico da divulgação indevida de informação privilegiada (prevista nos arts. 5º, I e 6º, I da LCI) que conta com redação similar no inciso III do art. 11 da LIA.

Nesse mesmo sentido, mas tecendo argumentação crítica[2] às mudanças da LIA, posicionam-se os promotores de justiça, Igor Pinheiro e Henrique da Rosa Ziesemer, em livro sobre o tema:

> *Há, porém, outro detalhe que não pode passar despercebido:* ***ao ter-se como válido o rol taxativo anunciado pelo 'caput' do artigo 11, o legislador conseguiria anular outras tipificações de improbidade administrativa previstas na legislação extravagante*** *e que são também comportamentos violadores dos princípios e merecedores de punições exemplares. Cito, como exemplo, o caso da "Lei*

2 "Não há dúvidas, portanto, que a expressão "caracterizada por uma das seguintes condutas" viola diretamente os princípios republicanos, da responsabilidade e da proporcionalidade (na vertente da proibição de proteção deficiente contra a probidade administrativa), sendo necessária a declaração de inconstitucionalidade do artigo 11, com a redução daquele texto" (PINHEIRO; ZIESEMER, 2021, p. 44).

> *do Conflito de Interesses*" (*Lei nº 12.813/2013*), *cujo artigo 12 diz que o agente público que praticar os atos previstos nos arts. 5º e 6º desta Lei incorre em improbidade administrativa, na forma do art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, quando não caracterizada qualquer das condutas descritas nos arts. 9º e 10 daquela Lei* (PINHEIRO; ZIESEMER, 2021, p. 46, *grifos nossos*).

Restaria, assim, a possibilidade de enquadramento dos atos de conflito de interesse nos arts. 9º e 10 da LIA, conforme parte final do art. 12 da LCI.

Dentro da dimensão repressiva da LCI prevista em seu art. 12, portanto, observa-se um esvaziamento na aplicação do art. 11 da LIA, devendo o aplicador das normas caracterizar adequadamente a conduta que implique enriquecimento ilícito ou dano ao erário, conforme o caso.

C. DA MERA CONDUTA À EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RESULTADO

Diferentemente dos arts. 9º e 10 da LIA, os atos enquadráveis em seu art. 11 "independem do reconhecimento da produção de d*anos ao erário e de enriquecimento ilícito* dos agentes públicos" (BRASIL, 2021, art. 11, § 4º, *grifos nossos*). O parágrafo 4º do artigo 11 da LIA exige apenas a *lesividade relevante* (atraindo, a contrário senso, a aplicação do princípio da insignificância):

> § 4º *Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos* (BRASIL, 2021).

Entretanto, considerando a diminuição na área de aplicação do art. 11 da LIA, conforme abordado no item anterior, para que sejam aplicados seus arts. 9º e 10 devem ser demonstrados os resultados ligados, respectivamente, ao enriquecimento ilícito dos agentes públicos ou à produção de danos ao erário, conforme o caso concreto.

A LCI caminhou, no entanto, em outra direção ao preceituar, em seu art. 4º, § 2º, que "a ocorrência de conflito de interesses *independe* da existência de lesão ao patrimônio público, bem como do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo agente público ou por terceiro" (BRASIL, 2013, *grifo nosso*).

Esse dispositivo determina, portanto, que as meras condutas descritas pela LCI, independentemente de qualquer resultado, configuram atos de conflito de interesse. Com efeito, para os fins exclusivos da LCI, a conduta será analisada formalmente, sem a necessidade de comprovação do resultado.

A caracterização dos atos de conflito de interesse como atos de improbidade administrativa, porém, deverá ser realizada em estrita observância do sistema da nova LIA e, por essa razão, diferentemente do previsto na LCI, os arts. 9º e 10 da LIA exigirão, respectivamente, a demonstração dos resultados relativos ao enriquecimento ilícito ou ao dano ao erário.

D. (IM)POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO COM BASE NA LCI

O parágrafo único do art. 12 da LCI sujeita o agente público, que se encontrar em situação de conflito de interesses, à aplicação da penalidade disciplinar de demissão. Recorde-se o texto legal:

> Art. 12. O *agente público que praticar os atos previstos nos arts. 5º e 6º desta Lei incorre em improbidade administrativa, na forma do art. 11 da Lei nº 8.429, de*

> *2 de junho de 1992, quando não caracterizada qualquer das condutas descritas nos arts. 9º e 10 daquela Lei.*
>
> *Parágrafo único.* ***Sem prejuízo do disposto no caput e da aplicação das demais sanções cabíveis, fica o agente público que se encontrar em situação de conflito de interesses sujeito à aplicação da penalidade disciplinar de demissão,*** *prevista no inciso III do art. 127 e no art. 132 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou medida equivalente* (BRASIL, 2013, *grifos nossos*).

A despeito de opiniões que possam surgir em sentido contrário, parece preferível entender que a pena de demissão, prevista no parágrafo único acima transcrito, seria aplicável tão somente nas situações de conflito de interesses enquadráveis como atos de improbidade, tal como previsto no *caput* deste art. 12.

Os que concordam com essa opinião estão atentos às garantias constitucionais daquele que seja réu em processo sancionatório e lembram o brocardo "*simul stabant simul cadunt*", vale dizer, "juntos estavam, juntos caem".

Desse modo, caso não seja situação fática que se amolde à cabeça do artigo, o parágrafo não poderá sobreviver. Inversamente, será condição inafastável para possibilidade de aplicação da pena de demissão o enquadramento do ato de conflito de interesses como ato de improbidade administrativa na nova sistemática e, nessa hipótese, para além da improbidade, poderá ser sancionada, com base na LCI, pena de demissão.

Naturalmente que, se houver o enquadramento de qualquer conduta nos termos do Estatuto do Funcionário Público, Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o intérprete deverá se fundamentar nesse estatuto, abrindo-se a possibilidade de aplicação de diversos tipos de sanção, conforme "a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais" (BRASIL, 1990, art. 128).

O art. 13 da LCI reforça essa tese ao asseverar que o disposto em tal diploma

> *não afasta a aplicabilidade da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, especialmente no que se refere à apuração das responsabilidades e possível aplicação de sanção em razão de prática de ato que configure conflito de interesses ou ato de improbidade* ***nela previstos*** (BRASIL, 2013, *grifos nossos*).

De acordo com o comando do art. 13 da LCI, portanto, os atos de conflito de interesse que porventura tenham qualquer consequência sancionatória não inviabilizarão processos administrativos disciplinares, que seguirão de maneira autônoma, observadas as previsões da Lei 8.112/1990.

No processo administrativo disciplinar com base no Estatuto do Funcionário Público, o agente público estará sujeito às penalidades de advertência, suspensão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada ou, se for o caso, à penalidade de demissão.

Essas consequências fazem transparecer a redução do escopo da dimensão repressiva da LCI, em virtude da nova sistemática da LIA, repercutindo na aplicação do *caput* e do parágrafo único do art. 12 acima transcritos.

CONCLUSÃO

Podem ser sintetizadas as repercussões ocorridas a partir da reforma da Lei de Improbidade Administrativa sobre as normas repressivas da Lei de Conflito de Interesses da seguinte maneira:

i) as situações de conflito de interesse que não tiverem a comprovação do dolo específico não poderão ser enquadradas como atos de improbidade administrativa;

ii) em função da nova sistemática (*numerus clausus*) adotada para a tipificação dos atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública (art. 11 da LIA), a aplicação do trecho do art. 12 da LCI que fazia remissão a esse artigo fica esvaziada, tendo em vista que apenas a conduta relativa ao uso indevido de informação privilegiada tem previsão "na forma do art. 11";

iii) as previsões de "mera conduta" cedem lugar à necessidade de comprovação do resultado para a comunicação entre ambos os sistemas e, por conseguinte, reduzem o escopo de enquadramento, na LIA, de atos de conflito de interesse meramente formais, não incidindo especificamente para essa esfera repressiva relacionada à improbidade a previsão do art. 4º, § 2º da LCI; e

iv) não há possibilidade de aplicação da pena de demissão, com base na LCI, em seu art. 12, parágrafo único, para os casos que não puderem ser enquadrados na nova LIA, operando-se a máxima "*simul stabant, simul cadunt*". Portanto, caso não seja possível a subsunção da situação fática no *caput* do art. 11 da LIA, não se poderá aplicar o seu parágrafo que prevê a penalidade de demissão atrelada às situações de conflito (diferentemente do previsto no art. 13 da LCI).

Essas conclusões levam em consideração, sobretudo, (i) a ênfase preventiva adotada pela LCI, tornando-se crucial a realização, por parte do agente público, de consulta, de boa-fé, para se certificar de que não irá praticar qualquer ato descrito nos arts. 5º ou 6º da lei; (ii) a necessidade de haver um sistema coerente para que se entre na esfera repressiva da LCI por meio da aplicação de seu art. 12, que faz a ligação com o sistema da improbidade administrativa; e (iii) o caráter sancionador da LIA que atrai as garantias fundamentais previstas na Constituição, conforme ressalta o jurista Marçal Justen Filho:

> *Por decorrência, a repressão à improbidade, tal como contemplada na lei 8.429, compreende as* ***garantias próprias do direito sancionatório****. Essas garantias (inclusive constitucionais) encontram-se formalmente consagradas a propósito do Direito Penal, mas também se aplicam no tocante à punição pela improbidade.*
>
> *Há uma proximidade intensa quanto à natureza, às peculiaridades e ao regime do Direito Penal e do sancionamento à improbidade* (JUSTEN FILHO, 2022, p. 25, *grifos nossos*).

O combate à corrupção, em sentido amplo, não pode prescindir de adequadas tipificações de atos de improbidade administrativa nas leis especiais, como é o caso da LCI. Tais normas especiais devem estar em harmonia com a nova LIA, sob pena de ser violada a garantia fundamental de legalidade, a exigir a adequada tipicidade da conduta infracional. Nesse sentido, invocamos novamente Marçal Justen Filho:

> *Isso significa a exigência indispensável da tipicidade da conduta infracional, da presença de um elemento subjetivo reprovável, da proporcionalidade da temporariedade no sancionamento e assim por diante* (JUSTEN FILHO, 2022, p. 26).

As repercussões da reforma da LIA na LCI fazem transparecer, portanto, a redução do escopo de aplicação das previsões repressivas dessa última lei e a necessidade de se interpretar o art. 12 da LCI à luz do novo sistema da LIA.

Certamente essas mudanças ocasionarão um maior direcionamento de algumas situações de conflito de interesse para outros campos, diferentes da improbidade administrativa, tais como o enquadramento na seara disciplinar (os processos conduzidos por corregedorias) ou no âmbito da ética (as averiguações por parte das respectivas comissões).

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Lei nº 8.112, de 11 de janeiro de 1990*. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm. Acesso em: 9 maio 2022.

BRASIL. *Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992*. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm. Acesso em: 9 fev. 2022.

BRASIL. *Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013*. Dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego; e revoga dispositivos da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, e das Medidas Provisórias nºs 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e 2.225-45, de 4 de setembro de 2001. Brasília, DF: Presidência da República, 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12813.htm. Acesso em: 9 fev. 2022.

BRASIL. *Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021*. Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14230.htm. Acesso em: 9 fev. 2022.

JUSTEN FILHO, Marçal. *Reforma da Lei de Improbidade Administrativa comentada e comparada*: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2022.

PINHEIRO, Igor Pereira; ZIESEMER, Henrique da Rosa. *Nova Lei de Improbidade Administrativa Anotada e Comparada*. São Paulo, SP: Mizuno, 2021.

A GOVERNANÇA PÚBLICA DA INFORMAÇÃO: TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA

*Humberto Eustáquio César Mota Filho**

RESUMO

Este artigo explora a literatura da governança pública da informação buscando respostas para a seguinte pergunta: como tratar dados com transparência e segurança jurídica? Para tanto, aborda inicialmente as lógicas da *accountability* e dos laços de confiança no setor público, tendo como baliza alguns marcos legais e as boas práticas que fornecem as normas, diretrizes e os controles de responsabilidade aplicáveis aos dados. Com efeito, apontam-se quais seriam as melhores estratégias para desenvolver políticas públicas que contribuam para o valor, a qualidade e o *compliance* das informações.

Palavras-chave: Governança pública. Transparência. Segurança jurídica. Proteção de dados.

* Advogado do BNDES. Doutor em Ciência Política (Iuperj). Mestre em Direito (Ucam). Pós-graduado em Comércio Internacional (Shanghai Business School), Direito da Empresa e da Economia (FGV) e em Projetos Financeiros (UERJ). Bacharel em Direito (PUC/Rio). Coordenador da Pós-Graduação Master Compliance do IAG/PUC. Presidente do Conselho Empresarial de Governança e Compliance da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Presidente da Comissão de Estudos da Transparência Pública da OAB/RJ. Consultor jurídico e professor. Membro do Fórum da Justiça na Era Digital da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro (Emerj). Autor de livros e artigos jurídicos e palestrante em eventos nacionais e internacionais. Ex-Conselheiro de Governança da Autoridade Pública Olímpica (APO). O conteúdo desse trabalho é de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.

INTRODUÇÃO

Em 2014, o International Data Corporation (IDC) estimou que os dados digitais criados, replicados e consumidos no mundo no período de um ano dobrariam de tamanho a cada dois anos, alcançando 44 zettabytes (ou 44 trilhões de gigabytes) em 2020 (IDC, 2014). Novos marcos legais e a expansão do universo digital obrigam as organizações a reavaliar suas estratégias em relação à guarda e ao uso da informação. Governos, empresas e indústrias estão se tornando mais digitais, dependentes das novas tecnologias de comunicação e conectividade, em um contexto caracterizado pelo crescimento acentuado do volume e da complexidade dos dados. Nessa sociedade do conhecimento, tanto as novas oportunidades quanto os novos desafios levam à seguinte pergunta: como gerar valor para as organizações a partir do gigantesco universo digital (FARIA; SYMPSON, 2014)? Uma possível resposta é investir na governança da informação.

Se a abundância de informação nas organizações oferece um grande potencial de desenvolvimento social e econômico, ela também traz riscos operacionais e legais que precisam ser geridos e mitigados. É fundamental, portanto, investir em governança para criar estratégias, políticas e procedimentos em torno da distribuição da informação dentro e fora das organizações. Em termos gerais, é possível afirmar que a governança da informação é o conjunto de normas, diretrizes e controles de responsabilidade desenvolvido para assegurar o valor, a qualidade e o *compliance* das informações.

Associada tanto à governança pública quanto à governança corporativa, a governança da informação está intimamente relacionada aos princípios da transparência e da prestação de contas (*accountability*). Isso porque tanto cidadãos quanto executivos e governantes necessitam de informações confiáveis para a tomada de decisões e para assegurar que seus dados estão protegidos e não foram adulterados, corrompidos, destruídos, descartados ou tratados e armazenados de forma indevida. Daí se revela a importância de outra indagação presente em todas as organizações atualmente: como tratar dados com transparência e segurança jurídica?

O termo "dados" costuma ser utilizado como sinônimo de informação, mas há também quem reconheça uma distinção semântica importante entre os dois (DONEDA, 2020). Ao se fazer essa distinção, o termo ganha conotação mais fragmentada, sugerindo uma informação em estado potencial, antes de ser transmitida, ou um estado de "pré-informação", anterior à interpretação e ao processo de elaboração, enquanto o vocábulo "informação" alude a algo além da representação contida no dado, sendo capaz, por isso mesmo, de se revestir de sentido instrumental e fornecer conteúdo voltado à redução de incertezas. De todo modo, é preciso ter em mente todo o ciclo de vida dos dados ao se buscar uma estratégia para tratá-los com transparência e segurança jurídica. Isso significa que a organização deve ser capaz de assegurar o valor, a qualidade e o *compliance* dos dados ou informações necessários às suas atividades ao longo do tempo, desde o momento da decisão de tratar determinado dado ou informação até a escolha de eliminá-lo de seus arquivos.

Então, cabe indagar quais são as melhores estratégias para fazer avançar uma agenda de governança da informação, especialmente porque não existe algo como uma receita única de sistema de governança ou de *compliance* (MENZEL, 2005).

Este artigo sugere um caminho que favoreça a busca por essa resposta partindo de marcos legais brasileiros e critérios objetivos que possam ser seguidos por governos e empresas públicas na governança de suas informações – em especial na coleta, no tratamento, armazenamento e eliminação de documentos e dados. Nesse sentido, são sugeridas quais as lógicas reitoras das políticas públicas voltadas a essa modalidade de governança no campo da transparência e da segurança da informação e são destacadas algumas de suas principais diretrizes, controles e responsabilidades.

Em outras palavras, propõe-se que a governança pública da informação seja aferida, em boa medida, pelos elementos da transparência e da segurança da informação, e são apontadas algumas

medidas e práticas que podem contribuir para o seu avanço em nosso país a partir de dispositivos legais específicos.

I. INFORMAÇÕES TRANSPARENTES: A LÓGICA DA *ACCOUNTABILITY*

Crises de confiança nas instituições, crises econômicas, precarização do bem-estar social e problemas em serviços públicos levam a um descontentamento generalizado com o Estado e com as corporações empresariais. As demandas por mais *accountability* desafiam as ordens políticas vigentes, já que esta é um princípio fundamental das democracias por meio do qual governantes e administradores prestam contas de suas ações aos cidadãos e ao mercado, podendo ter seu comportamento autorizado, chancelado ou simplesmente sofrer sanções em caso de mau desempenho, ineficiência, corrupção ou arbitrariedade no uso do poder.

De fato, a noção de *accountability* sugere um processo abrangente, envolvendo não apenas instituições representativas, mas também organizações da burocracia e outras com atores não eleitos (OLSEN, 2018). Há enormes variações no que se entende por e no que implica a *accountability*, pois é ainda um conceito em evolução (CAMPOS, 1990) que comporta uma nova reflexão sobre a ordem política e um princípio de organização das relações entre governados e governantes, proprietários e não proprietários.

Nessa evolução, é importante notar que o termo não parece se esgotar nas preocupações da administração pública tradicional, em uma *accountability* de processos, restrita ao exame da conformidade das leis e normas procedimentais, a partir de um ponto de vista hierárquico e descomprometido com resultados. Em uma acepção mais abrangente, *accountability* alude à responsabilidade perante alguém, a uma obrigação dos governantes ou administradores de explicarem e justificarem suas ações – por exemplo, como mandatos e contratos foram tratados, como a autoridade e os recursos foram aplicados e quais foram os resultados (OLSEN, 2018).

Mais especificamente, a lógica da *accountability* democrática corresponde a uma série de mecanismos pelos quais os agentes públicos são obrigados a prestar contas por seu desempenho e suas atividades em relação aos cidadãos (ABRUCIO; LOUREIRO, 2005). Essa lógica demanda uma interação qualificada Estado-sociedade, baseada em transparência, imputabilidade, controle, responsabilidade e responsividade (KOPPELL, 2005) e dever de justificativa – *answerability* (FIABANE, 2011; SCHEDLER, 1999).

Ao compreender essa lógica de uma interação mais qualificada, a definição de O'Donnell de *accountability* horizontal para as relações entre atores estatais das diversas esferas de poder, sem a ideia de hierarquia, e de *accountability* vertical para identificar a relação principal-agente ou mandante-mandatário, pela qual o titular originário das prerrogativas relacionadas ao exercício do poder político as transfere para representantes dele incumbidos, afigura-se insuficiente. Assim, o controle do poder público e da prestação de serviços públicos demanda mobilização, interlocução e articulação dos mais diversos atores públicos e privados na produção, tratamento e disponibilização de informações destinadas aos órgãos de controle estatal e aos cidadãos diretamente.

Numa dinâmica de "círculo virtuoso", informações transparentes tendem a favorecer a lógica da *accountability* democrática e estimular uma interação mais qualificada entre atores públicos e privados. É possível criar e manter um fluxo de informações transparentes a partir de um conjunto dado de normas, diretrizes e controles de responsabilidade desenvolvido para assegurar o valor, a qualidade e o *compliance* das informações, para o qual algumas políticas públicas podem contribuir.

A. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INFORMAÇÕES MAIS TRANSPARENTES

A governança da informação relaciona-se com questões públicas fundamentais. Na ótica da governança pública, sua boa execução requer transparência dos atos de governo – ou seja, a prestação de contas pela produção e divulgação sistemática de informações (MOTA FILHO; ALFRADIQUE, 2018) – e objetiva a geração de benefícios sociais. Nessa visão normativa de governança pública, a prestação de contas dos administradores públicos é compreendida como um bem básico da democracia – a *accountability* democrática (DIAMOND, 1999). Tanto é assim que, para os próprios conselheiros de administração das estatais federais, o maior avanço da Lei das Estatais (Lei 13.303, de 30 de junho de 2016) consistiu na determinação de mais transparência na divulgação das informações relevantes (SARDENBERG, 2018, p. 14).

A publicidade dos atos de governo é uma das bases do estado democrático de direito consagrado pela constituinte de 1988. Segundo os próprios constituintes, o acesso às informações dos órgãos públicos é fundamental para o aperfeiçoamento da máquina de governo, para a correção de eventuais abusos, para o combate à corrupção e para o exercício pleno da cidadania. Por essas razões, o direito à informação está inscrito no rol de direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 5º, XIV e XXXIII).

Em busca de mais legitimidade e da recuperação da confiança de seus cidadãos, governos democráticos investem na transparência e na divulgação de seus atos e políticas públicas, tal como as empresas em relação aos consumidores e ao público em geral. Assim o fazem por acreditarem que, ao se tornarem mais conhecidos e compreendidos, a confiança do público em suas ações será recuperada ou aumentará, então, as políticas públicas e as políticas corporativas terão mais chances de avançar e obter melhores resultados se contarem com mais credibilidade e apoio.

O conceito de transparência na gestão pública se divide em duas vertentes: a ativa e passiva. A primeira é caracterizada pela publicação e disseminação de forma proativa, pelo poder público, de informações essenciais sobre suas políticas e ações – em portais da transparência, por exemplo –, sem necessidade de pedidos prévios. Já na transparência passiva, o poder público fornece informações mediante solicitações e pedidos realizados pela sociedade civil organizada, por empresas ou por qualquer cidadão, atuando de forma reativa.

Políticas de dados abertos (PDA) tendem a qualificar o diálogo público-privado e agregam credibilidade às informações públicas repassadas, permitindo que as políticas públicas sejam concebidas, implementadas e avaliadas com base em melhores critérios e que se aumente a participação social em todas as fases de seu ciclo de desenvolvimento. Nessa lógica, o Governo Federal brasileiro regulamentou recentemente uma PDA (Decreto 8.777, de 11 de maio de 2016) contendo princípios orientadores e objetivos, dentre os quais destacam-se: (i) promover a publicação de dados da administração pública federal; (ii) aprimorar a cultura de transparência pública; (iii) franquear aos cidadãos o acesso aos dados produzidos ou acumulados pelo Poder Executivo federal sobre os quais não recaia vedação expressa de acesso; (iv) facilitar o intercâmbio de dados entre a administração pública federal e as diferentes esferas da federação; e (v) fomentar o controle social e o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática e à melhor oferta de serviços públicos para o cidadão.

Segundo a PDA, dados abertos são aqueles "acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte" (BRASIL, 2016a, art. 2º, III). Complementando tal definição, vale notar que os dados considerados acessíveis ao público são aqueles gerados ou acumulados pelo Governo Federal que não estejam sob sigilo ou sob restrição de acesso nos termos da Lei de Acesso à Informação. Então, geralmente, é responsabilidade dos órgãos e entidades públicas assegurar a gestão

transparente da informação, propiciando amplo acesso e divulgação, vedando o acesso do público apenas em casos excepcionais (BRASIL, 2011, art. 6º, I).

Entre suas responsabilidades, a Controladoria Geral da União (CGU) – órgão de controle interno do Governo Federal – deve zelar pelo incremento da transparência da gestão pública. Para tanto, conta com um portal de dados abertos, no qual estão disponíveis informações sobre auditorias realizadas, empresas inidôneas e suspensas e processos disciplinares, em linha com os objetivos expressos na PDA.

Mas é possível ir além para o avanço da governança da informação no âmbito da transparência pública, especialmente na questão da qualidade da informação, ao tratar os dados para demonstrar como uma organização pública gera valor. Lançado em 2014 pelo Conselho Internacional para Relato Integrado (International Intregrated Reporting Council – IIRC) – uma coalizão global de reguladores, investidores, empresas, organismos de normatização, entidades contábeis e organizações não governamentais (ONG) –, o relato integrado tem exatamente o objetivo de articular informações financeiras e não financeiras, de forma concisa, para demonstrar como uma organização gera valor para seus públicos de relacionamento.

Já existem alguns exemplos de promoção do relato integrado em nosso país. Em geral, a adoção do modelo pelo setor privado é voluntária, mas iniciativas do governo começam a tornar sua utilização obrigatória para alguns entes públicos. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, por exemplo, devem divulgar anualmente relatório integrado ou de sustentabilidade (BRASIL, 2016b, art. 8º). Recentemente, o Tribunal de Contas da União (TCU) promoveu mudanças no processo de prestação de contas anuais da administração pública federal, incluindo a adoção do modelo do relato integrado para o relatório de gestão (TCU, 2018). Com essa exigência válida para todos os órgãos e entidades da administração pública, as mais de 1,1 mil unidades que prestam contas ao TCU deverão adotar esse modelo.

Políticas públicas podem favorecer uma boa governança da informação sempre que fornecerem os meios para que a transparência ativa e passiva esteja a serviço da prestação de contas dos administradores públicos (*accountability* democrática). Dito de outro modo, a governança da informação pública terá mais legitimidade e credibilidade se o conjunto de suas normas, diretrizes e controles de responsabilidade assegurar os valores da prestação de contas e da informação pública, a qualidade da informação (pela adoção das boas práticas organizacionais e de gestão documental) e o *compliance* das informações (pela forma correta de coleta, tratamento, armazenamento e eliminação de dados pessoais e coletivos dos cidadãos), necessários ao desenvolvimento das políticas públicas. Alguns desses temas serão abordados mais adiante, ao tratar-se da segurança da informação.

II. INFORMAÇÕES SEGURAS: A LÓGICA DA CONFIANÇA

Segundo o dilema da confiança (MOTA FILHO, 2018), explorado por Ovanessoff, Plastino e Faleiro (2015), é preciso confiança para cooperar, entretanto, também é preciso cooperar para ganhar confiança, seja na interação de agentes públicos, de agentes privados ou entre agentes públicos e privados. De maneira geral, estudos apontam que a maioria dos brasileiros tem dificuldades para estabelecer novas relações de confiança (CNI, 2014), e que mesmo as empresas do país consideradas inovadoras colaboram menos com outras organizações nacionais ou internacionais do que as empresas de grande parte dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Essas lacunas na confiança social acabam por comprometer a colaboração necessária nas relações negociais. Por seu turno, nas relações público-privadas, não há razão para supor que o quadro é muito melhor.

Mais recentemente, foi feita uma pesquisa nacional a fim de investigar qual é o nível de confiança dos brasileiros em suas instituições, especificamente entre as ONGs, empresas, mídia e governo

(EDELMAN, 2017), e é revelador notar que nenhuma dessas organizações atingiu resultados satisfatórios. As ONGs e as empresas ao menos não despertaram a desconfiança entre os brasileiros, enquanto a mídia e o governo não mereceram confiança. O levantamento ainda revelou que a população do país considera suas fontes oficiais suspeitas, já que a maioria dos consultados considerou os indivíduos mais confiáveis do que as instituições e as informações vazadas como tendo mais credibilidade do que os comunicados das companhias para a imprensa.

Ainda que essa crise de confiança seja global, a chamada era da economia da reputação (FAGUNDES, 2017) parece intensificar suas consequências no ambiente empresarial brasileiro. Nessa nova economia da reputação, 84% do valor de mercado de uma empresa listada no índice Standard & Poor's 500 (S&P 500) dos Estados Unidos está atrelado a valores intangíveis, como a reputação, e o Brasil não parece fugir dessa tendência. Os riscos reputacionais estão no topo das preocupações dos membros dos conselhos de administração e, segundo pesquisas internacionais, as principais causas da perda de reputação são os comportamentos à margem da ética e da integridade (DELOITTE, 2014). Sem sombra de dúvida, no meio empresarial, a confiança é um ativo valioso e a falta de ética é um passivo fatal. Assim, um ambiente geral de baixa confiança social, como no caso brasileiro, afeta negativamente a sociedade, os negócios e o governo.

Todos esses dados indicam a necessidade de mais governança pública, ou seja, as soluções para o problema da confiança precisam ser legitimadas por uma agenda de mudança dos processos decisórios que inclua a sociedade desde o início das discussões. É preciso retomar níveis de confiança satisfatórios que permitam criar um ambiente propício ao debate público e ao desenvolvimento de mais negócios e investimentos em nosso país. Portanto, é fundamental enfrentar o problema da confiança com o diagnóstico e as ferramentas certas.

Para avançar nessa agenda de forma a fortalecer os laços de confiança sociais, a lógica da *accountability* é fundamental, mas não suficiente. Uma estratégia efetiva para o avanço da governança da informação demanda que, junto com a transparência das informações, seja garantida a sua segurança, pois assim será possível ganhar a legitimidade e a credibilidade necessárias para vencer o problema da confiança (MOTA FILHO, 2018). Nesse sentido, políticas públicas podem ajudar a fortalecer a segurança das informações utilizadas pelas organizações.

A. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INFORMAÇÕES MAIS SEGURAS

Na governança pública, a informação é um bem público, na medida em que atende a demandas públicas e se converte em direito constitucional dos cidadãos, conforme nosso ordenamento jurídico. O emprego de informações incorretas, corrompidas ou indevidas pode acarretar prejuízos substanciais às políticas públicas e tornar suas ações ineficazes ou contraproducentes.

Ninguém dúvida que as organizações governamentais armazenam e criam uma quantidade de informações cada vez maior a cada dia. Entretanto, essas informações nem sempre geram valor para as organizações, já que muitas vezes não têm a qualidade desejada nem estão em conformidade com as leis e seus regulamentos. Problemas com a governança da informação são cada vez mais frequentes nas organizações, sejam eles referentes a vazamentos de dados privilegiados, prejuízos decorrentes de ataques cibernéticos ou sistemas contábeis e controles bancários corrompidos, chegando até mesmo a casos de processos fraudulentos automatizados pelos sistemas de certos bancos (LAJARA, 2013).

Na sociedade do conhecimento, a segurança é um dos elementos característicos e essenciais da governança da informação (WILLIAMS, 2008). Em termos gerais, o conceito de segurança da informação envolve a proteção da confidencialidade, integridade e disponibilidade (acessibilidade) da informação (POSTHUMUS; VON SOLMS, 2004). Mais especificamente, segundo esses três pilares

norteadores, a segurança da informação deve garantir que ela: esteja acessível quando necessária para o funcionamento da organização e realização de seus fins (disponibilidade); seja acessada e utilizada exclusivamente por quem é devidamente autorizado para tal (confidencialidade); seja verídica e não esteja corrompida (integridade) (FONTES, 2000).[1]

Precisamente nessa linha, a Política Nacional de Segurança da Informação (PNSI), instituída no âmbito da Administração Pública Federal pelo Decreto 9.637, de 26 de dezembro de 2018, tem como objetivo assegurar a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade[2] da informação a nível nacional. A PNSI abrange os campos da segurança e defesa cibernética, segurança física e proteção de dados organizacionais. Sob a ótica dessa política, a governança da informação encontra, em termos gerais, as principais diretrizes desenvolvidas para assegurar a proteção de dados dessas organizações. Aqui vale ressaltar que é responsabilidade dos órgãos de governo, em todos os níveis, a proteção da informação custodiada por eles, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade, e a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal (BRASIL, 2011, art. 6º, II e III).

Mas antes mesmo da edição da PNSI, a Lei 12.682, de 9 de julho de 2012, já consagrava legalmente esses pilares ao dispor sobre o processo de digitalização, ou seja, "sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos" (BRASIL, 2012). Nesse sentido, nosso sistema legal já reconhecia que tal processo deveria ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).[3] Assim, por regra, para que haja validade jurídica ou valor probatório de uma cópia ou reprodução de um documento original, é preciso que alguém investido de fé pública[4] ateste, com segurança, que verificou os elementos de autoria e integridade do original em cotejo com a cópia apresentada naquele ato. Portanto, esses procedimentos também devem ser incluídos no rol de uma política de governança da informação.

Na seara da proteção de dados, vale recordar que tal matéria é disciplinada na Constituição Federal, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e no Marco Civil da Internet. Contudo, a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) singulariza-se por sua abrangência, enunciando princípios, direitos, responsabilidades e demais aplicações decorrentes do tratamento de dados pessoais. Portanto, vale concentrar nossa análise nesse marco regulatório em especial, pois ele estabelece as diretrizes para o tratamento dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado.

Tendo em conta esse histórico, resta claro que a LGPD está inserida num sistema legal de proteção de dados mais amplo, não detendo a exclusividade do tratamento legislativo sobre a proteção de dados pessoais. Ela certamente se aplica ao tratamento de dados por pessoa jurídica de direito público e impacta a governança pública ao buscar a proteção de direitos e garantias fundamentais da pessoa natural. Assim, na ocorrência de infrações à LGPD, em especial no caso de incidentes de segurança da informação, a autoridade regulatória avaliará a boa-fé do infrator, a implementação de políticas de

---

1 Conceitos técnico-legais de disponibilidade, autenticidade e integridade podem ser encontrados no art. 4º, incisos VI, VII e VIII, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011).

2 Aqui vale recordar que a autenticidade é uma qualidade do documento, ou seja, significa que aquele documento é o que diz ser, livre de qualquer adulteração e corrupção. Já a autenticação é uma declaração dessa qualidade, quer dizer, é uma manifestação sobre um documento, num determinado momento, por uma pessoa física ou jurídica investida de autoridade para fazer tal declaração (servidor público, notário ou autoridade certificadora). Portanto, procedimentos que visam a certificação de conferência com o original, por exemplo, tratam da questão da autenticação de uma cópia. A observância desses procedimentos é importante, pois afeta diretamente a segurança das informações.

3 "Art. 1º A digitalização, o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente e a reprodução de documentos públicos e privados serão regulados pelo disposto nesta Lei" (BRASIL, 2012).

4 Fé pública é o crédito que se deve dar a documentos emanados de autoridades públicas ou serventuários da justiça em virtude da função ou ofício exercido.

boas práticas e de governança e a pronta tomada de medidas corretivas, entre outros critérios (BRASIL, 2018b, art. 52, § 1º). Portanto, destaca-se a importância da adoção de uma política de governança da informação para a proteção de dados pessoais também no âmbito do setor público.

A LGPD aplica-se a qualquer órgão ou entidade pública, a empresas públicas e sociedades de economia mista, especialmente quando há utilização dos dados dos cidadãos para a elaboração e execução de políticas públicas e prestação de serviços públicos. Dessa forma, a implementação da LGPD no setor público exige a revisão de todos os processos que envolvam dados pessoais e sensíveis,[5] com o desenvolvimento de uma política de governança para o mapeamento e tratamento dessas informações em conformidade com a legislação. Essa nova lei dedicou todo um capítulo ao tratamento de dados pessoais pelo poder público em busca de estabelecer um equilíbrio entre o acesso à informação nas mãos da administração pública e a proteção dos dados pessoais dos cidadãos, fazendo ainda expressas menções à Lei de Acesso à Informação.[6]

É preciso cuidado especial nos casos de incidentes de segurança que possam acarretar riscos ou danos relevantes aos cidadãos, titulares das informações utilizadas pelo setor público. Vale recordar que diversos órgãos e entidades públicas lidam com dados pessoais tanto de contribuintes quanto de servidores e empregados públicos, por exemplo, sendo que muitos se enquadram na definição de dado pessoal sensível. Na ocorrência de incidente de segurança, é imprescindível comunicá-lo à Autoridade Nacional de Proteção de Dados[7] e ao titular dos dados, via órgão público, entidade pública, empresa pública ou sociedade de economia mista que desempenhar o papel de controlador, em um prazo razoável, sempre que o incidente de segurança puder acarretar risco ou dano relevante aos titulares.[8]

A segurança das informações também é impactada diretamente pela gestão da documentação governamental, que é regulada pela própria Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 216, § 2º), a qual determina que cabe à administração pública, na forma da lei, gerir e franquear a consulta dos arquivos públicos pela sociedade. Nessa esteira, foi promulgada a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados (PNAPP).

A PNAPP compreende a definição e adoção de um conjunto de normas e procedimentos técnicos e administrativos para disciplinar as atividades relativas aos serviços arquivísticos da administração pública, visando a melhoria desses arquivos no âmbito de um processo de reestruturação da própria administração. Nesse sentido, a política adota como objetivos do programa de gestão de documentos o controle sobre a produção documental e a racionalização de seu fluxo (BRASIL, 2002, art. 1º e art. 13, I-IV) para permitir, com isso, que os arquivos públicos cumpram sua função social,[9] aumen-

---

5 Dado pessoal é todo e qualquer dado que possa ser vinculado ou associado a uma determinada pessoa. Dados sensíveis são os que revelam origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa.

6 Várias regras foram criadas exclusivamente para órgãos e entidades públicos, como as relativas ao compartilhamento de dados pessoais à transparência e às bases autorizativas dos tratamentos de dados pessoais. Há previsão de diferentes sanções, a depender do regime concorrencial ou não da entidade pública, com impacto relevante para empresas públicas e sociedades de economia mista que ora atuam como entidades privadas, ora como gestoras ou executoras de políticas públicas.

7 O conteúdo dessa comunicação deve abarcar a descrição da natureza dos dados pessoais afetados; informações sobre os titulares envolvidos; indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados; riscos relacionados ao incidente; motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a depender da gravidade do incidente, pode determinar a adoção de outras providências, tais como a ampla divulgação do fato em meios de comunicação e medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente.

8 A ser definido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na legislação europeia que trata do mesmo tema (General Data Protection Regulation – GDPR), o prazo definido foi de 72 horas.

9 A função social dos arquivos é revelada pelo registro documental, que tem a capacidade de "capturar os fatos, suas causas e consequências, de preservar e estender no tempo a memória e a evidência desses fatos", atestar "ações e transações, e [...] sua veracidade dependente das circunstâncias de sua criação" (DURANTI, 1994, p. 49-64).

tem sua eficácia e garantam o cumprimento dos direitos da cidadania,[10] dando suporte às decisões político-administrativas do Estado (BRASIL, 2001).

Apesar de elaborada no início da era digital, ao incidir sobre a gestão e o ciclo de vida dos documentos de interesse público, a PNAPP também pode orientar o desenvolvimento de informações mais seguras se harmonizada com os diplomas legais mais recentes da Política de Segurança da Informação e da LGPD, especialmente na questão da integridade e da eliminação dos documentos.

Para cumprir a PNAPP e os objetivos da gestão de documentos, foi organizado um código de classificação de documentos de arquivo para a administração pública aprovado pelo Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), vinculado ao Arquivo Nacional. Mas os próprios representantes do Conarq reconhecem que as atividades da administração pública são dinâmicas e requerem alterações periódicas, a fim de garantir sua atualidade frente às constantes transformações desse setor (BRASIL, [2019]).

Assim sendo, a eliminação de documentos no setor público obedece a procedimentos previstos na legislação arquivística específica (BRASIL, 1996, art. 1º e 2), entre os quais estão a constituição de comissão permanente de avaliação de documentos, a elaboração de tabela de temporalidade e destinação de documentos e o cumprimento do disposto nas resoluções do Conarq que tratam da eliminação de documentos. No setor público, a eliminação deve ser precedida pela elaboração de listagem que, depois de aprovada pela instituição arquivística com esfera de competência específica, deverá ser publicada; quando for efetivada a eliminação, será lavrado o termo de eliminação de documentos, segundo a legislação vigente. Caso o original seja considerado de valor permanente, não poderá ser eliminado, conforme também determina a legislação. Nesse sentido, a observância da PNAPP pretende garantir segurança jurídica na eliminação dos documentos dos arquivos públicos.

Indo além, é fundamental incluir no planejamento de governança da informação do setor público a avaliação do alinhamento entre os prazos constantes na proposta de arquivamento de documentos[11] e os prazos prescricionais previstos no ordenamento jurídico para a defesa dos direitos reais e pessoais dessas entidades.

Afinal, o Poder Judiciário[12] entende que as ações de ressarcimento de danos ao erário, em determinadas hipóteses, são imprescritíveis. Ou seja, no limite, os órgãos e empresas públicas podem ser demandados a produzir, por tempo indeterminado, documentos relativos a condutas suspeitas de terem gerado dano ao erário público. Nesse contexto, recomenda-se especial cuidado na classificação, manutenção e eliminação de arquivos públicos que, por sua natureza, documentem operações com maiores riscos potenciais de caracterizar algum dano relevante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O emprego das lógicas da *accountability* e dos laços de confiança contribui para o tratamento de dados de forma transparente e segura no setor público. Os marcos legais e as boas práticas de mercado existentes já servem de guia para a identificação das normas, diretrizes e controles de responsabilidade aplicáveis aos dados. A partir daí, é fundamental traçar as estratégias para

10 Na administração pública, graças à Constituição Federal de 1988, os arquivos estão associados à conquista de direitos civis e ao exercício pleno da cidadania. No capítulo sobre os direitos e garantias fundamentais, a Carta Magna assegurou a todos o direito ao acesso à informação e a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral (art. 5º, incisos XIV e XXIX), conferindo assim um papel de destaque à formulação de política pública de gestão de documentos, nos termos da Lei 8.159/1991, que regulamentou o artigo 216 da Constituição Federal.

11 Código de classificação e tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-fim das entidades públicas previstos na PNAPP.

12 O Superior Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" (BRASIL, 2019).

desenvolver e aplicar políticas públicas que contribuam para o valor, a qualidade e o *compliance* das informações.

Políticas públicas mais transparentes devem estar a serviço da prestação de contas dos administradores públicos e dos resultados de suas ações e omissões (*accountability* democrática). Desse modo, as políticas públicas para proteção de dados devem fortalecer os três pilares que norteiam a segurança da informação: estar acessível quando necessária para o funcionamento da organização e realização de seus fins (disponibilidade); ser acessada e utilizada exclusivamente por quem é devidamente autorizado para tal (confidencialidade); e ser verídica e não estar corrompida (integridade).

A governança da informação pública terá mais legitimidade e credibilidade, portanto, se o conjunto de suas normas, diretrizes e controles de responsabilidade assegurar os valores da prestação de contas e da informação pública, bem como a qualidade da informação, pela adoção das boas práticas organizacionais e da gestão documental, e o *compliance* das informações, pela forma correta de coleta, tratamento, armazenamento e eliminação de dados pessoais e coletivos dos cidadãos – dados esses que são necessários ao desenvolvimento das políticas públicas.

REFERÊNCIAS

ABRUCIO, Fernando Luiz; LOUREIRO, Maria Rita. Finanças públicas, democracia e *accountability*: debate teórico e o caso brasileiro. *In:* ARVATE, Paulo Roberto; BIDERMAN, Ciro (org.). *Economia do setor público no Brasil*. Rio de Janeiro: Elsevier/Campos, 2005. p. 75-102.

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 nov. 2021.

BRASIL. Arquivo Nacional. Conselho Nacional de Arquivos. *Classificação, temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da administração pública*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001.

BRASIL. Arquivo Nacional. Conselho Nacional de Arquivos. Resolução n. 5, de 30 de setembro de 1996. Dispõe sobre a publicação de editais para Eliminação de Documentos nos Diários Oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, p. 20558, 11 out. 1996.

BRASIL. Decreto n. 4.073, de 3 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, p. 1, 3 jan. 2002.

BRASIL. Decreto n. 8.777, de 11 de maio de 2016. Institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, p. 21, 12 maio 2016a.

BRASIL. Decreto n. 9.637, de 26 de dezembro de 2018. Institui a Política Nacional de Segurança da Informação, dispõe sobre a governança da segurança da informação [...]. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, ed. 248, p. 23, 27 dez. 2018a.

BRASIL. Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, p. 455, 9 jan. 1991.

BRASIL. Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, p. 1, 18 nov. 2011.

BRASIL. Lei n. 12.682, de 9 de julho de 2012. Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, p. 1, 10 jul. 2012.

BRASIL. Lei n. 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, p. 1, 1 jul. 2016b.

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, ed. 157, p. 59, 15 ago. 2018b.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Perguntas mais frequentes. *Conarq*, Rio de Janeiro, [2019]. Disponível em: http://antigo.conarq.gov.br/documentos-eletronicos-ctde/perguntas-mais-frequentes.html. Acesso em: 16 jul. 2018.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 852.475/SP. Direito constitucional. Direito administrativo. Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Sentido e alcance do art. 37, § 5 °, da constituição [...]. Relator: Alexandre de Moraes. Relator do Acórdão: Edson Fachin, 8 de agosto de 2018. *Diário Eletrônico da Justiça*, São Paulo, n. 58, 25 mar. 2019.

CAMPOS, Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português? *Revista de Administração Pública*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 30-50, 1990.

CAVOUKIAN, Ann. *Privacy by design*: the 7 foundational principles. Toronto: Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2011. Disponível em: www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/resources/7foundationalprinciples.pdf. Acesso em: 12 jun. 2018.

CNI – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Pesquisa CNI-Ibope*: retratos da sociedade brasileira: confiança interpessoal, março de 2014. Brasília, DF: CNI, 2014.

DELOITTE. *2014 global survey on reputation risk*: Reputation@Risk. New York: Deloitte, 2014. Disponível em: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Governance-Risk-Compliance/gx_grc_Reputation@Risk%20survey%20report_FINAL.pdf. Acesso em: 12 jun. 2018.

DIAMOND, Larry. *Developing democracy*: toward consolidation. Baltimore: John Hopkins University Press, 1999.

DONEDA, Danilo. O direito fundamental à proteção de dados pessoais. *In:* MARTINS, Guilherme Magalhães; LONGHI, João Victor Rozatti (org). *Direito digital*: direito privado e internet. São Paulo: Foco, 2020. p. 33-51.

DURANTI, Luciana. Registros documentais contemporâneos como prova de ação. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, p. 49-64, 1994.

EDELMAN. *2017 Edelman Trust Barometer*: trust and the CEO. Chicago: Edelman, 2017. Disponível em: https://www.ifac.org/system/files/uploads/Comms/Day%201%20-%20Trust%20Barometer%20-%20Justin%20Blake.pdf. Acesso em: 12 jun. 2018.

FAGUNDES, Suzana. Integridade como novo paradigma da reputação. *Revista Governança e Compliance da Associação Comercial do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 30-33, 2017.

FARIA, Fernando A.; SYMPSON, Gladys E. Bridging the gap between business and IT: an information governance perspective in the banking industry. *In:* BHANSALI, Neera. *Data governance*: creating value from information assets. Boca Raton: Taylor & Francis, 2014. p. 217-241.

FIABANE, Danielle Fabian. *Controle social*: um novo frame nos movimentos sociais. 2011. Dissertação (Mestrado em Administração Pública e Governo) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2011.

FONTES, Edison. *Vivendo a segurança da informação*: orientações práticas para pessoas e organizações. São Paulo: Sicurezza, 2000.

IDC – INTERNATIONAL DATA CORPORATION. *The digital universe of opportunities*: rich data and the increasing value of the internet of things. Needham: IDC, 2014. Disponível em: https://www.iotjournaal.nl/wp-content/uploads/2017/01/idc-digital-universe-2014.pdf. Acesso em: 12 jun. 2018.

JIMENE, Camilla do Vale. Da segurança e das boas práticas. *In:* MALDONADO, Viviane Nóbrega; BLUM, Renato Opice. *LGPD*: Lei geral de proteção de dados comentada. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 329-354.

KOPPELL, Jonathan G. S. Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of "multiple accountabilities disorder". *Public Administration Review*, Hoboken, v. 65, n. 1, p. 94-108, 2005.

LAJARA, Tamara Tebaldi. *Governança da informação na perspectiva de valor, qualidade e compliance*: estudo de casos múltiplos. 2013. Dissertação (Mestrado em Administração) – Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.

MENZEL, Donald C. Research on ethics and integrity in governance: a review and assessment. *Public Integrity*, Abingdon, v. 7, n. 2, p. 147-168, 2005.

MOTA FILHO, Humberto. Como manter um ambiente ético nas empresas? *Revista Compliance Rio*, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 30-37, 2018.

MOTA FILHO, Humberto; ALFRADIQUE, Cláudio Nascimento. A governança e o controle da função pública: a transparência pública nos trinta anos da Constituição Cidadã. *In:* MONTEIRO, Geraldo Tadeu Moreira (org.).

Estado, democracia e direito no Brasil: trinta anos da constituição cidadã. Rio de Janeiro: Gramma, 2018. p. 413-436.

OLSEN, Johan P. *Accountability democrática, ordem política e mudança*: explorando processos de accountability em uma era de transformação europeia. Tradução: Eliane Rio Branco. Brasília, DF: Enap, 2018.

OVANESSOFF, Armen; PLASTINO, Eduardo; FALEIRO, Flaviano. *Por que o Brasil precisa aprender a confiar na inovação colaborativa.* São Paulo: Accenture, 2015.

POSTHUMUS, Shaun; VON SOLMS, Rossouw. A framework for the governance of information security. *Computers & Security*, Amsterdam, v. 23, n. 8, p. 638-646, 2004.

SARDENBERG, Dalton. *Integridade pública, regulação e controle social.* Seminário de Governança Privada e Integridade Pública da Associação Comercial do Rio de Janeiro, 7 jun. 2018.

SCHEDLER, Andreas. Conceptualizing accountability. *In:* SCHEDLER, Andreas; DIAMOND, Larry; PLATTNER, Marc F. (ed.). *The self-restraining state*: power and accountability in new democracies. Boulder: Lynne Rienner, 1999. p. 13-28.

TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Decisão Normativa TCU n. 170, de 19 de setembro de 2018. Dispõe acerca das unidades cujos dirigentes máximos devem prestar contas de suas gestões ocorridas no exercício de 2018, especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa TCU 63, de 1º de setembro de 2010. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, ed. 187, p. 107, 24 set. 2018.

WILLIAMS, Patricia A. H. In a "trusting" environment everyone is responsible for information security. *Information Security Technical Report*, Amsterdam, v. 3, n. 4, p. 207-215, 2008.

Editado pelo Departamento de Comunicação do Gabinete da Presidência do BNDES
Junho de 2022

BNDES O banco nacional do desenvolvimento

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL